

판례평석: 취업규칙 변경 동의의 주체가 되는 근로자집단의 범위 (2009두2238, 대법원 2009.5.28. 선고)

1. 사건의 개요

이 사건은 원고 신용협동조합(이하 '조합'이라 한다)이 상무로 근무하던 관리직 근로자(이하 '관리직 근로자'라 한다)가 정년에 도달하였다는 이유로 해고한 것에 대한 사건이다.

조합은 1973년 설립인가를 받아 전주시에 본점을 두고 상시근로자 35명을 고용하여 금융업을 영위하는 신용협동조합이고, 관리직 근로자는 1976년에 입사하여 2001년도에 상무로 진급하고 그 후 중앙지소 지점장으로 발령받아 근무를 하다가 2007.6.30. 자로 정년면직처리(이하 '이 사건 해고'라 한다)된 사람이다.

관리직 근로자는 2007년 7월 전북지방노동위원회에 이 사건 해고가 부당하다는 취지로 부당해고구제신청을 했고, 전북지방노동위원회는 관리직의 정년을 60세에서 58세로 변경할 때 관리직 직원들의 동의를 얻었다고 볼 수 없다는 등의 이유로 이 사건 해고를 부당해고로 인정했다. (2007부해113, 2007.8.30.)

이에 조합은 2007년 9월 중앙노동위원회에 부당해고 구제재심신청을 하였고, 중앙노동위원회는 전북지방노동위원회와 같은 이유로 조합의 재심신청을 기각하는 판정을 내렸다. (2007부해762호, 2007.9.18.)

2. 판결의 요지

2.1 원심판결요지

1심과 2심에서는 이 사건 해고가 부당하다고 본 중앙노동위원회의 재심판정을 취소했다. 이유는 조합이 관리직 근로자의 정년을 60세에서 58세로 낮추는 취업규칙의 불이익변경을 할 때 불이익변경의 대상이 되는 근로자집단인 관리직 직원(12명)의 집단적인 의사결정방법에 의한 동의가 없었다는 것이다.

2.2 대법원판결요지

대법원에서는 원심판결을 파기하고 사건을 고등법원에 환송했다. 이유는 정년규정의 개정에 대한 동의주체가 당시 3급 이상이었던 현재 관리직인 직원 11명뿐만이 아니라 앞으로 승진하여 관리직이 될 수 있는 가능성이 있는 일반직 직원들을 포함한 전체 직원이라는 것이다.

3. 대상판결의 검토

3.1 쟁점사항

이 판결의 쟁점사항은 한 기업 내에 여러 근로자 집단이 있고, 각각의 집단에 대한 근로조건에 차이가 존재하는 경우에 취업규칙의 불이익변경의 동의주체가 되는 근로자의 범위를 어떻게 정해야 하는지이다.

취업규칙의 법적 성질과 같은 취업규칙 관련 다른 쟁점사항들은 이 판결에서 직접적으로 다루어지지 않았으나, 판례평석 과정에서 필요한 쟁점사항에 대해서 추가적으로 논의한다.

3.2 취업규칙 제도에 대한 이해

사건을 정확하게 이해하기 위해서는 우선 이 사건의 핵심 쟁점인 취업규칙의 개념, 법적 성질, 적용 범위, 불이익변경의 법리 등에 대해서 알아보고, 이 사건의 사실관계에 대해서도 보다 구체적으로 알아볼 필요가 있다.

취업규칙의 개념

취업규칙이란 그 명칭이 무엇이든지 관계없이 근로자에 대한 근로조건과 복무규율에 관한 기준을 집단적이고 통일적으로 설정하기 위하여 사용자가 일방적으로 작성한 준칙이다.

근로기준법에 따르면 모든 사용자가 취업규칙을 작성해야 하는 것은 아니다. 상시 10명 이상의 근로자를 사용하는 사용자에게 한해 취업규칙을 작성 및 신고할 의무가 부여된다. 취업규칙에 포함되어야 하는 내용은 다음과 같다.

근로기준법 제93조(취업규칙의 작성·신고) 상시 10명 이상의 근로자를 사용하는 사용자는 다음 각 호의 사항에 관한 취업규칙을 작성하여 고용노동부장관에게 신고하여야 한다. 이를 변경하는 경우에도 또한 같다.

1. 업무의 시작과 종료 시각, 휴게시간, 휴일, 휴가 및 교대 근로에 관한 사항
2. 임금의 결정·계산·지급 방법, 임금의 산정기간·지급시기 및 승급(昇給)에 관한 사항
3. 가족수당의 계산·지급 방법에 관한 사항
4. 퇴직에 관한 사항

5. 「근로자퇴직급여 보장법」 제4조에 따라 설정된 퇴직급여, 상여 및 최저임금에 관한 사항
6. 근로자의 식비, 작업 용품 등의 부담에 관한 사항
7. 근로자를 위한 교육시설에 관한 사항
8. 출산전후휴가·육아휴직 등 근로자의 모성 보호 및 일·가정 양립 지원에 관한 사항
9. 안전과 보건에 관한 사항
 - 9의2. 근로자의 성별·연령 또는 신체적 조건 등의 특성에 따른 사업장 환경의 개선에 관한 사항
10. 업무상과 업무 외의 재해부조(災害扶助)에 관한 사항
11. 직장 내 괴롭힘의 예방 및 발생 시 조치 등에 관한 사항
12. 표창과 제재에 관한 사항
13. 그 밖에 해당 사업 또는 사업장의 근로자 전체에 적용될 사항

이와 같이 취업규칙은 사실상 근로조건에 대한 대부분의 내용을 포함하고 있기 때문에 현실에서 근로계약이나 단체협약보다 더 중요한 역할을 담당하는 경우가 많다.

취업규칙은 근로자 집단에 적용될 집단적 근로조건을 설정하는 수단이라는 점에서 개별적 근로조건 설정 수단인 근로계약과 구별되고, 단체협약과 유사한 측면이 존재한다. 취업규칙이나 단체협약에 따라 설정되는 집단적 근로조건과 개별 근로계약에 의하여 설정되는 개별적 근로조건은 구별되어야 한다. 개별적 근로조건은 사용자와 개별 근로자의 동의가 있다면 법에 위반되지 않는 범위 내에서 비교적 쉽게 변경할 수 있고, 집단적 근로조건인 취업규칙과 단체협약은 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 근로자대표(이하 '노동조합 또는 근로자대표'라 한다)와의 협의 내지 동의 절차를 거쳐야 한다.

취업규칙의 경우 작성 또는 변경에 관하여 노동조합 또는 근로자대표의 의견을 듣는 것으로 충분하지만, 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 동의를 받아야 한다.(근로기준법 제94조제1항)

근로기준법 제94조(규칙의 작성, 변경 절차) ① 사용자는 취업규칙의 작성 또는 변경에 관하여 해당 사업 또는 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수의 의견을 들어야 한다. 다만, 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 그 동의를 받아야 한다.

취업규칙의 법적 성질

사용자가 일방적으로 작성한 취업규칙이 근로자를 법적으로 구속할 수 있는 법규인지 아니면 양 당사자의 합의를 매개로 하는 계약인지에 대해 의견이 나뉜다.

다수의 판결에서 근로기준법이 종속적 노동관계의 현실에 입각하여 실질적으로 불평등한 근로자의 입장을 보호강화하여 그들의 기본적 생활을 보호·향상시키려는 목적의 일환으로 그 작성

을 강제하고, 법규범성을 부여한 것이라고 판시한 것을 근거로 판례는 취업규칙을 법규로 본다고 해석한다.

대법원 77다355 판결 중 판결요지

가. 취업규칙은 근로기준법이 근로자 보호의 목적으로 그 작성을 강제하고 이에 법규범성을 부여한 것이므로 이를 근로자에게 불이익하게 변경하려면 종전 취업규칙의 적용을 받고 있던 근로자 집단의 집단의사결정방법에 의한 동의를 요한다.

취업규칙의 적용범위

취업규칙은 해당 사업 또는 사업장 단위로 작성이 의무화되어 있는만큼 적용 역시 사업 또는 사업장 단위라고 보는 것이 타당하다. 즉, 취업규칙은 사용자와 근로계약관계를 맺은 사업장 내 근로자라면 원칙적으로 적용대상이 된다. 다만, 취업규칙의 내용이 전체 근로자 중 특정한 집단에만 적용되는 내용인 경우에는 해당 취업규칙은 특정한 근로자들에게만 적용될 것이다.

다른 집단적 근로조건 설정 수단인 단체협약의 경우에는 노동조합에 가입한 근로자에게만 적용되는 반면, 취업규칙은 노동조합 가입여부와 관계없이 전체 근로자에게 적용된다는 점이 다르다.

취업규칙의 작성과 변경

상시 10명 이상의 근로자를 사용하는 사용자는 취업규칙을 작성해야 한다. 상시 10명 미만의 근로자를 사용할 때는 취업규칙 작성의무가 없다. 따라서 상시 근로자가 10명이 되는 시점을 기준으로 지체없이 취업규칙을 작성해야 하는 것으로 판단되며, 작성 기한에 대해서는 별도의 규정이 없어 상시 근로자가 10명이 되었는데도 상당한 기간동안 취업규칙을 작성하지 않은 경우에는 취업규칙 작성의무를 위반한 것으로 본다.

취업규칙을 최초로 작성할 때에는 그 내용의 유효리와 관계없이 노동조합 또는 근로자대표의 의견을 듣는 것으로 절차적 정당성이 확보된다.

취업규칙을 최초로 작성하여 고용노동부장관에게 신고한 이후에는 취업규칙을 변경할 수 있다. 취업규칙의 변경도 원칙적으로는 노동조합 또는 근로자대표의 의견을 청취하는 절차를 거쳐 가능하다. 다만 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 그렇지 않다.

취업규칙의 불이익변경

근로기준법 제94조제1항은 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우(불이익변경)에는 그 동의를 받아야 한다고 규정하고 있다. 즉, 불리하지 않은 취업규칙의 변경은 노동조합 또는 근로자대표의 의견 청취 절차만 거쳐도 가능하지만, 불리한 변경은 노동조합 또는 근로자대표의 동의를 받아야 한다.

취업규칙의 불이익변경과 관련한 몇 가지 쟁점이 있는데, 어떤 취업규칙 변경이 불이익한 변경인지 아닌지에 대한 판단 기준, 일부 근로자들에게만 불이익한 변경인 경우 불이익 변경의 동의

주체가 누구인지 여부, 집단적 동의의 방법 및 효력 등이다.

이 사건에서는 불이익변경의 동의주체가 누구인지가 핵심 쟁점이고, 이와 함께 나머지 쟁점에 대해서도 필요에 따라 검토하기로 한다.

3-3. 이 사건의 구체적 사실관계 및 검토의견

이 사건 사실관계는 다음과 같다.

- 조합이 정년과 관련된 인사규정을 개정할 당시(2003년 12월) 전체 직원은 38명이었고, 그 중 관리직 직원은 12명이었다.
- 조합에는 전체 근로자 중 27명이 가입한 노동조합이 있었으며, 노동조합에는 관리직 3급 4명과 일반직 23명 등 총 27명이 가입해 있었다.
- 조합은 인사규정 중 관리직(3급 이상)은 60세, 일반직(4급 이하)는 55세로 되어 있는 정년규정을 관리직과 일반직 모두 동일하게 58세로 변경하기로 2003.12.30. 의결하였으며, 노동조합은 2004년 10월 조합원 27명 전체의 출석하에 임시총회를 개최하여 찬성 22표, 반대 5표로 인사규정 개정에 대한 동의안을 통과시켰다.

개정 전 인사규정 제11조의 2(직원의 정년) : 직원의 정년은 다음과 같다.

1. 관리직 직원 : 60세
2. 일반직(관리직 제외), 기능직, 고용직 직원 : 55세

개정 후 인사규정 제27조(정년) ① 직원의 직급별 정년은 다음과 같다.

1. 사무직 : 58세
2. 계약직은 이사회에서 정한 바에 의한다.
3. 삭제

이 사건 관리직 근로자는 개정된 인사규정에 근거하여 60세가 아닌 58세 정년규정을 적용받아 본인의 예상보다 2년 빨리 해고되었고, 이에 대해 부당해고라고 주장하였다.

이 사건의 발단이 되는 조합의 인사규정 개정은 관리직(3급 이상)의 정년을 60세에서 58세로 낮추고, 일반직(4급 이하)의 정년을 55세에서 58세로 높이는 내용이다. 정년이 낮아질수록 일할 수 있는 기간이 줄어들기 때문에 이 인사규정 개정은 관리직 근로자에게는 불리하고 일반직 근로자에게는 유리한 취업규칙 변경으로 볼 수 있다.

이와 같이 복수의 취업규칙 규정을 동시에 변경하면서 일부 사항은 근로자에게 불리하게, 일부 사항은 근로자에게 유리하게 변경할 경우, 해당 취업규칙의 변경을 종합적으로 비교형량하여 불이익변경 여부를 판단할 것인지 아니면 근로조건 항목마다 변경 전후의 규정을 개별적으로 비교하여 불이익변경 여부를 판단할 것인지 문제된다.

근로조건 항목마다 변경 전후의 규정을 개별적으로 비교하여 불이익변경 여부를 판단해야 한다는 입장(이를 '개별판단설'이라 하자)에 따르면 취업규칙의 변경이 전체적으로는 근로자에게 유리하다고 판단되더라도 그 중 일부의 내용이 근로자에게 불리한 경우 노동조합 또는 근로자대표의 동의를 받아야 한다.

개별판단설의 장점은 근로자의 근로조건이 저하되는 것을 엄격하게 방지할 수 있다는 것이다. 근로자의 근로조건은 다양한 측면에서 정해지는데, 취업규칙의 변경을 통해 어느 하나의 조건이라도 저하하려고 하는 사용자는 노동조합 또는 근로자대표의 동의를 받아야만 하기 때문에 기존에 정해진 근로조건이 저하되는 것을 사실상 금지하는 효과가 있다. 물론 근로자들이 회사 사정이나 경영상황 등을 고려하여 근로조건의 저하에 동의할 수 있으나, 이는 전체 사업장 중에서 극히 일부의 사업장에서 이뤄지는 예외적인 상황이라고 보아야 할 것이다.

또 다른 장점은 취업규칙의 변경이 불이익한지 여부를 따지기가 상대적으로 쉬워진다는 것이다. 취업규칙의 중의 일부가 불리하고 일부가 유리하다고 할 때 두 가지 부분을 합쳤을 때 종합적으로 불리한 것인지 유리한 것인지 판단하는 것은 매우 어려운 일이다. 단순한 임금 인상 및 삭감과 같이 명확히 계산이 되는 경우라면 문제가 없겠지만, 임금 외에 근로시간, 업무강도, 복리후생 등 다양한 요인에 영향을 주는 취업규칙 변경이라면 판단하는 사람에 따라 기준에 따라 유불리 여부가 달라질 수 밖에 없다.

해당 취업규칙의 변경을 종합적으로 비교衡量하여 불이익변경 여부를 판단해야 한다는 입장(이를 '종합판단설'이라 하자)에 따르면 취업규칙은 하나하나의 조건이 유리한지 불리한지를 따지는 것이 아니라 변경되는 조건을 종합적으로 고려하여 해당 취업규칙 변경이 불이익변경에 해당하는지를 판단한다.

종합판단설의 장점은 사용자가 근로자의 근로조건을 경영상황에 따라 보다 유연하게 조정할 수 있다는 것이다. 사용자는 기업이 시장에서 생존할 수 있도록 여러가지 경영상의 의사결정을 해야하며, 필요에 따라 근로자의 근로조건을 변경해야 할 필요성이 있다. 대표적인 예로 업무량의 증가·감소에 따라 근로시간을 변경하고, 그에 따라 임금수준을 조정하는 결정을 할 수 있다. 이와 같은 결정은 필연적으로 근로자의 근로조건에 유리한 부분과 불리한 부분이 함께 포함되어 있을 수 밖에 없는데, 그 중 일부에 근로조건이 불리하게 변경되는 부분이 있다는 이유로 노동조합 및 근로자대표의 동의를 얻도록 한다면 상황에 따른 경영상의 의사결정을 하기 어려워 질 수 있다.

판례는 퇴직금 관련 조항의 개정을 다룬 94다18072(대법원 1995.3.10.) 판결과 2018다255488(대법원 2022.3.11.) 판결 등에서 종합판단설의 입장을 취하고 있는 것으로 보인다.

대법원 1995. 3. 10. 선고 94다18072 판결 [퇴직금] 판결요지 가. 취업규칙의 일부를 이루고 있는 급여규정 개정의 유·무효를 판단함에있어서 우선 퇴직금 지급률이 전반적으로 인하되어 그 자체가 불리한 것이라고 하더라도 그 지급률의 인하와 함께 다른 요소가 유리하게 변경된 경우에는 그 대가관계나 연계성이 있는 제반 상황(유리하게 변경된 부분 포함)을 종합 고려하여 과연 그 퇴직금에 관련한 개정 조항이 유리한 개정인지 불리한 개정인지를 밝혀서 그 유·불리를 함께 판단하여야 할 것이고, 그 종합 판단의 결과 불리한

개정으로 밝혀진 경우(일부 근로자에게는 유리하고 일부 근로자에게는 불리하여 근로자 상호간에 유·불리에 따른 이익이 충돌되는 경우도 이와 같다)에는 종전의 급여규정을 적용받고 있던 근로자 집단의 집단적 의사결정에 의한 동의를 받을 것을 요하고 그러한 동의가 없는 경우에는 그 변경은 효력을 가질 수 없다.

대법원 2022. 3. 11. 선고 2018다255488 판결 [근무형태변경시행무효확인] 상고이유를 판단한다.

1. 근로기준법 제94조 제1항 단서에서 정한 취업규칙의 불이익 변경이란 사용자가 종전 취업규칙 규정을 개정하거나 새로운 규정을 신설하여 근로조건이나 복무규율에 관한 근로자의 기득권·기득이익을 박탈하고 근로자에게 저하된 근로조건이나 강화된 복무규율을 일방적으로 부과하는 것을 말한다(대법원 1993. 8. 24. 선고 93다 17898 판결 등 참조). 취업규칙의 변경이 근로자에게 불이익한지 여부를 판단할 때 근로조건을 결정짓는 여러 요소 중 한 요소가 불이익하게 변경되더라도 그와 대가관계나 연계성이 있는 다른 요소가 유리하게 변경되는 경우라면 그와 같은 사정을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2004. 1. 27. 선고 2001다42301 판결 등 참조).

취업규칙의 변경이 복수의 근로조건을 변경할 때, 해당 취업규칙 변경이 불이익한지 여부를 판단하는 기준은 개별 요소들을 판단하여 각각의 요소들에 대하여 유불리를 정하는 방식보다 종합적으로 판단하는 것이 타당하고 또 바람직하다고 생각한다.

사용자와 근로자의 관계는 근로계약에 기초한 사용종속관계이기도 하지만, 함께 기업의 생존과 성장을 위해 노력하는 동반자 관계이기도 하다. 사용자가 기업의 성장을 위해서 또는 기업의 위기를 극복하기 위해서 근로조건을 변경하는 것은 경영권의 가장 본질적인 의사결정이며, 취업규칙의 변경이 종합적으로 판단했을 때 근로자에게 불리하지 않다면 이는 경영권의 일부로 인정해주어야 한다.

다만, 이러한 주장에 대해 크게 2가지 반론이 있을 수 있다.

첫 번째는 그렇다면 복수의 근로조건을 변경하는 취업규칙의 변경이 유리한지 불리한지 '종합적으로' 판단하는 기준이 애매하다는 것이다. 어떠한 변화가 나에게 유리한지 불리한지에 대한 판단은 개인마다 다를 수 있다. 따라서 집단적 근로조건 결정수단인 취업규칙의 변경이 종합적으로 유리한지 불리한지는 판단하기 매우 어려울 것이다.

복수의 근로조건을 변경하는 취업규칙 변경을 종합적으로 판단해보았을 때 결과적으로 유리하다고 판단된다면 노동조합 또는 근로자대표의 의견을 청취하는 것으로 족하다. 따라서 종합적으로 유리한 취업규칙 변경이라고 판단했을 때는 법률적으로 큰 문제가 발생하지 않는다.

문제는 종합적으로 판단해보았을 때 불리한 취업규칙 변경이라고 판단된 경우이다. 취업규칙을 변경한 사용자나 취업규칙 변경에 동의한 일부 근로자가 있다고 하더라도 종합적으로 불리한 취업규칙 변경이라고 판단된 이상 노동조합 또는 근로자대표의 동의를 받아야 한다. 다만 유불리여부를 판단하기 애매한 취업규칙 변경에 대해서까지 사용자가 노동조합 또는 근로자대표의

동의를 받기 어렵다는 현실을 반영하여 대법원은 비록 불리한 취업규칙 변경이라고 하더라도 사회통념상 합리성이 있으면 불이익한 변경이 아니라는 판례를 상당기간 유지해왔다.

대법원 1978. 9. 12. 선고 78다1046 판결 [급여금등] 판결요지 조합이 근로자의 정년규정이 없던 종전 취업규칙을 변경하여 그 정년을 만 55세까지로 정한 것은 사회의 일반통례에서 벗어난 불합리한 제도라고 볼 수 없는 것이므로 근로자의 동의없이 하여도 그 변경은 유효하다.

그렇지만 최근 대법원은 전원합의체 판결(2017다35588, 대법원 2023.5.11.)에서 사용자가 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하면서 근로자의 집단적 의사결정방법에 따른 동의를 받지 못한 경우, 노동조합이나 근로자들이 집단적 동의권을 남용하였다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 해당 취업규칙의 작성 또는 변경에 사회통념상 합리성이 있다는 이유만으로 그 유효성을 인정할 수는 없다고 하였다.

대법원 2023. 5. 11. 선고 2017다35588 판결 [부당이득금반환] 판결요지 (가) 사용자가 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하면서 근로자의 집단적 의사결정방법에 따른 동의를 받지 못한 경우, 노동조합이나 근로자들이 집단적 동의권을 남용하였다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 해당 취업규칙의 작성 또는 변경에 사회통념상 합리성이 있다는 이유만으로 그 유효성을 인정할 수는 없다. (나) 근로기준법상 취업규칙의 불이익변경 과정에서 노동조합이나 근로자들이 집단적 동의권을 행사할 때도 신의성실의 원칙과 권리남용금지 원칙이 적용되어야 한다. 따라서 노동조합이나 근로자들이 집단적 동의권을 남용하였다고 볼 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 그 동의가 없더라도 취업규칙의 불이익변경을 유효하다고 볼 수 있다. 여기에서 노동조합이나 근로자들이 집단적 동의권을 남용한 경우란 관계 법령이나 근로관계를 둘러싼 사회 환경의 변화로 취업규칙을 변경할 필요성이 객관적으로 명백히 인정되고, 나아가 근로자의 집단적 동의를 구하고자 하는 사용자의 진지한 설득과 노력이 있었음에도 불구하고 노동조합이나 근로자들이 합리적 근거나 이유 제시 없이 취업규칙의 변경에 반대하였다는 등의 사정이 있는 경우를 말한다. 다만 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에 근로자의 집단적 동의를 받도록 한 근로기준법 제94조 제1항 단서의 입법 취지와 절차적 권리로서 동의권이 갖는 중요성을 고려할 때, 노동조합이나 근로자들이 집단적 동의권을 남용하였는지는 엄격하게 판단할 필요가 있다.

이는 1978년 이후 취업규칙 변경에 있어서 유지되어온 '사회통념상 합리성'이 있으면 취업규칙의 불이익변경이 아니라고 본 법원의 의견을 철회한 것으로, 취업규칙 변경이 불이익한지 아닌지는 '사회통념상 합리성'에 대한 고려없이 취업규칙 자체만을 보고 판단할 수 있게 되었다.

'사회통념상 합리성'만 있으면 취업규칙 불이익변경이 가능했었던 기존 입장에서 '집단적 동의권의 남용'과 같은 특별한 사정이 있어야만 취업규칙 불이익변경이 가능해졌다. 따라서 노동조합 및 근로자대표의 동의없는 취업규칙 불이익변경의 가능성은 크게 축소되었다고 볼 수 있다.

이러한 판례의 변화는 "근로조건의 노사대등결정 원칙, 근로자의 권익 보장에 관한 근로기준법의 근본정신, 기득권 보호의 원칙"과 "취업규칙의 본질적 기능과 불이익변경과정에서 필수적으

로 확보되어야 하는 절차적 정당성의 요청"을 지키기 위한 것이다. 또한 근로조건의 유연한 조정은 사용자에 의한 일방적 취업규칙 변경을 폭넓게 승인함으로써가 아니라, 단체교섭이나 근로자의 이해를 구하는 사용자의 설득과 노력을 통해서 이루어져야 한다고 명시하였다.

추가로 법원은 불리한 취업규칙 변경에 대해 노동조합 또는 근로자대표가 집단적 동의권을 행사할 때도 신의성실의 원칙과 권리남용금지 원칙이 적용되어야 한다고 하면서, 노동조합이나 근로자들이 집단적 동의권을 남용하였다고 볼 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 그 동의가 없더라도 취업규칙의 불이익변경을 유효하다고 하였다. 불이익한 취업규칙의 변경에 대한 집단적 동의권을 강화하면서 발생할 수 있는 부작용을 최소화하기 위한 안전장치로 볼 수 있다. 아직 집단적 동의권의 남용에 대한 기준이 정의되지 않았기 때문에 집단적 동의권 남용 기준 및 범위에 대한 사회적 논의를 통해 불필요한 논란을 최소화할 필요가 있다.

두 번째는 해당 사업의 근로자 집단에 따라 각각 적용되는 취업규칙은 종합적으로 판단하는 것이 타당하지 않다는 것이다. 취업규칙이 해당 사업내의 특정한 사업장에서 일하는 근로자에게만 적용되거나, 특정한 직군에만 적용되거나, 그 밖에 특정한 조건을 갖춘 사람들에게만 적용된다면 그 취업규칙의 변경은 취업규칙이 적용되는 대상 근로자들만을 대상으로 유불리를 정하고, 불리한 경우에는 동의를 받아야 한다고 지적할 수 있다.

법원은 93다1893(대법원 1993.5.14.) 판결에서 취업규칙의 변경이 일부의 근로자에게는 유리하고 일부의 근로자에게는 불리한 경우 근로자들 전체의 의사에 따라 결정하게 하는 것이 타당하다는 입장이다.

대법원 1993. 5. 14. 선고 93다1893 판결 [퇴직금] 판결요지 취업규칙의 일부를 이루는 급여규정의 변경이 일부의 근로자에게는 유리하고 일부의 근로자에게는 불리한 경우 그러한 변경에 근로자집단의 동의를 요하는지를 판단하는 것은 근로자 전체에 대하여 획일적으로 결정되어야 할 것이고, 또 이러한 경우 취업규칙의 변경이 근로자에게 전체적으로 유리한지 불리한지를 객관적으로 평가하기가 어려우며, 같은 개정에 의하여 근로자 상호간의 이, 불리에 따른 이익이 충돌되는 경우에는 그러한 개정은 근로자에게 불이익한 것으로 취급하여 근로자들 전체의 의사에 따라 결정하게 하는 것이 타당하다.

본 판결에서도 취업규칙 변경에 대한 집단적 동의를 받아야 하는 근로자의 범위를 판단하고 있는데, 이 사건의 취업규칙 변경은 근로조건이 이원화되어 있는 경우로 보아 변경된 취업규칙이 적용되어 불이익을 받는 근로자 집단만이 동의주체가 된다고 보았다.

대법원 2009. 5. 28. 선고 2009두2238 판결 이유 ... (중략) ... 여러 근로자 집단이 하나의 근로조건 체계 내에 있어 비록 취업규칙의 불이익변경 시점에는 어느 근로자 집단만이 직접적인 불이익을 받더라도 다른 근로자 집단에게도 변경된 취업규칙의 적용이 예상되는 경우에는 일부 근로자 집단은 물론 장래 변경된 취업규칙 규정의 적용이 예상되는 근로자 집단을 포함한 근로자 집단이 동의주체가 되고, 그렇지 않고 근로조건이 이원화되어 있어 변경된 취업규칙이 적용되어 직접적으로 불이익을 받게 되는 근로자 집단 이외에 변경된 취업규칙의 적용이 예상되는 근로자 집단이 없는 경우에는 변경된 취업규칙이 적용되어 불이익을 받는 근로자 집단만이 동의주체가 된다. ... (중략) ...

1심과 2심에서는 직접적으로 정년이 단축되는 관리직 근로자들을 동의 대상으로 보고, 12명의 관리직 근로자들에게 동의를 받지 않았기 때문에 취업규칙의 변경은 무효라고 판단하였다. 3심에서는 이와 달리 4급 이하의 일반직 직원들도 누구나 3급 이상으로 승진할 가능성이 있기 때문에 3급 이상의 관리직 직원뿐만 아니라 일반직 직원들을 포함한 전체 직원들이 동의주체가 되어야 한다고 보았다.

여기서 첫 번째 쟁점은 일부의 근로자들에게만 불리하게 적용될 것으로 예상되는 취업규칙의 변경에 대해서 불이익을 받는 근로자 집단만 동의주체가 되어야 하는지 아니면 전체 근로자가 동의주체가 되어야 하는지이다.

본 판결의 입장과 같이 불이익을 받는 근로자 집단만 동의주체가 되려면 근로조건이 이원화되어야 한다. 그런데 근로조건의 이원화라는 것은 과거뿐만 아니라 향후에도 보장되어야 하는 조건인데, 아직 미래가 오지 않은 상태에서 근로조건의 이원화가 보장되기는 어렵다. 즉, 인사발령, 사업구조의 개편, 그 밖의 여러 사정변경에 따라 근로조건의 이원화는 형해화될 수 있는데 취업규칙의 불이익변경의 동의대상으로 특정한 근로자 집단을 지정하는 것은 위험한 판단으로 보인다.

따라서 93다1893 판결의 입장과 같이 일부의 근로자에게는 유리하고 일부의 근로자에게는 불리한 경우 종합적으로 해당 취업규칙의 변경이 불이익변경으로 판단되었다면 근로자 전체를 동의 주체로 해야한다고 생각한다. 단체협약의 경우 노동조합의 가입이라는 명확한 기준이 있어 가입한 사람에게는 적용되고 가입하지 않은 사람에게는 적용되지 않아도 문제가 없지만, 취업규칙에 따른 근로자 집단의 구분은 법적으로 보장되는 내용이 아니고 언제든지 바뀔 수 있는 것이므로 취업규칙 변경의 동의대상을 일부 근로자 집단으로 나누는 것은 신중하게 접근해야 한다.

본 판결에서는 불이익을 받는 근로자 집단만이 동의주체가 된다는 전제는 받아들여지, 관리직 정년의 단축은 현재 관리직뿐만 아니라 향후 관리직으로 승진할 수도 있는 일반직도 동의주체가 되어야 한다는 판단을 한 것이다. 이러한 판단에 대해 추가적으로 의견을 제시하면, 일반직이라고 해도 모든 직원이 관리직이 될 수 있는 것은 아니다. 예를 들어 연령이 높은 낮은 직급의 일반직 근로자가 있다면 관리직 근로자가 될 가능성이 없다고 볼 수 있는데, 이런 근로자도 동의주체에 포함되어야 할까? 또는 본인이 관리직으로서의 승진을 원하지 않는 직원이 있다면 어떨까? 결론적으로 일반직이라고 해서 모두가 관리직으로 승진할 수 있는 가능성이 있다고 본 것은 지나치게 개인의 특성을 무시한 판단이라고 비판받을 수 있다.

이러한 문제가 발생한 근본적인 원인은 근로조건의 이원화를 인정하고, 이에 따라 근로자 집단을 나눌 수 있다고 본 것에 있다. 따라서 일부 근로자에게는 유리하고 일부 근로자에게 불리한 취업규칙 변경이 있는 경우에는 전체 근로자를 동의주체로 하는 것이 보다 타당하다고 생각한다.

4. 결론

4-1. 2009두2238 판례에 대한 종합 의견

본 판결에 따르면 2003년 12월에 이뤄진 취업규칙 변경은 노동조합의 동의를 받은 것으로 볼 수 있다. 즉, 관리직 근로자의 해고는 부당해고가 아니다.

집단적 동의절차를 필요로 하는 단체협약의 체결, 취업규칙의 불이익변경은 그 내용에 따라 직접적으로 영향을 받는 근로자들의 동의만 얻어도 되는 것이 아닌지에 대한 의견이 지속적으로 제기될 것으로 예상된다. 왜냐하면 자신과 직접적으로 관련이 없을 것으로 예상되는 내용에 대하여 의사결정을 해야한다는 것이 합리적이지 않게 느껴질 수 있기 때문이다.

하지만 노동법의 기본적인 취지는 근로자가 집단을 이룸으로써 사용자와 대등하게 대화할 수 있다는 것이다. 비록 근로자들 사이에 차이가 있다고 하더라도 그 차이를 서로 이해하고, 상대방의 입장에서 생각하며 나아가 사용자와도 협력적인 관계를 형성하는 것이 노동법의 근본적인 목적이라고 생각한다. 그러한 관점에서 볼 때 집단적 동의 절차를 잘게 쪼개어 개별적인 성격을 강화시키는 것은 비록 해당 사건에서는 타당하게 보일 수 있지만 전체 노동법 체계에서는 바람직하지 못한 접근이 될 우려가 있다.

4-2. 취업규칙 제도의 발전 방향

사용자와 근로자는 근로계약관계이며, 상당히 오랜 기간동안 지속될 것을 예정하고 있는 사람과 사람과의 관계이기도 하다.

이 점을 고려하여 취업규칙 제도의 발전방향은 크게 3가지로 제안한다.

첫째, 취업규칙을 대폭 간소화해야 한다.

현재 근로기준법에 따르면 취업규칙은 임금, 근로시간, 각종 수당, 교육, 안전·보건 등 매우 다양한 내용을 세세하게 정해야 한다. 고용노동부가 작성한 표준취업규칙은 전체 페이지가 60쪽이 넘으며, 조항만 100개에 육박한다. 대부분의 기업에서 취업규칙을 제대로 알고 있는 근로자는 거의 없다. 왜냐하면 내용이 너무 많고, 법령과 비교하면서 이해하기가 쉽지 않기 때문이다.

취업규칙에서 정하도록 하는 내용 중에 상당수는 이미 법령에 있는 내용이며, 취업규칙은 이를 그대로 적어둔 경우에 불과한 경우가 많다. 따라서 불필요하게 많은 내용을 취업규칙에 정하도록 하기보다 법령에서 정하지 않은 내용에 대해서만 보완적으로 정하도록 하면 현장에서 취업규칙에 대한 이해도가 크게 개선될 수 있을 것이다. 정말 필요한 내용만 간소하게 정하도록 해서 누구나 자신이 근무하고 있는 기업의 취업규칙을 이해할 수 있도록 해야 한다.

둘째, 모든 사업장에서 취업규칙을 작성하도록 해야 한다.

취업규칙의 간소화와 연결되어 있는 문제이기도 한데, 취업규칙은 근로계약, 단체협약과 함께 근로조건을 결정하는 중요한 제도이다. 그런데 상시 10명 이하의 근로자를 사용하는 사용자는 취업규칙을 작성하지 않아도 된다는 것은 제도의 공백이 생길 수 밖에 없다는 것을 의미한다.

최근 근로기준법도 5인 미만 사업장에 대해 적용을 확대하는 방안을 검토하고 있는데, 이와 함께 취업규칙의 작성 범위도 규모와 관계없이 모든 사업장으로 확대하는 방안을 검토할 필요가 있다.

물론 모든 사업장에 취업규칙을 작성하도록 하려면 첫번째로 제안한 취업규칙의 간소화가 획기적으로 이뤄져야 한다. 지금과 같이 60쪽에 해당하는 취업규칙을 영세사업장에게 작성하도록 하는 것은 합리적이지 않기 때문이다.

셋째, 취업규칙 변경이 불이익한 변경인지 아닌지 판단해주는 절차를 신설할 필요가 있다.

우리나라의 노동조합 조직율은 점차 감소되는 추세이며, 대부분의 영세사업장에는 노동조합이 존재하지 않는다. 취업규칙과 관련된 문제는 근로조건 개선에 대한 요구가 증가하면서 점차 중요도가 높아질 것이다. 이에 대응하기 위해 취업규칙 변경에 대한 1차적인 판단을 제공해줄 행정절차를 신설할 필요가 있다.

취업규칙의 변경이 불이익한 변경인지에 대해 갈등이 발생했을 때 지방노동위원회와 중앙노동위원회를 통해 불이익 여부를 1차적으로 판단해줄 절차가 있다면 취업규칙과 관련한 갈등이 해소될 수 있을 것으로 판단된다. 공무원노동관계 조정 위원회나 차별시정위원회 처럼 별도의 목적을 가진 위원회를 신설하여 취업규칙 관련 문제를 전문적으로 판단하도록 하면 소송 등을 통해 법원의 판단을 받는 것보다 신속하게 갈등이 해결될 수 있을 것으로 보인다.

이와 같은 취업규칙 제도의 변화는 일방적으로 설계하기보다는 노-사-정이 함께 논의할 수 있는 공론장을 형성하고, 여기에서 충분한 기간동안의 토론을 통해 사회적으로 합의할 수 있는 안을 만들어 추진하는 방식으로 진행된다면 취업규칙 제도가 근로조건 결정에 기여할 수 있는 제도로 발전할 수 있을 것이다.